

论行政诉讼补救判决的适用

——基于 104 份行政裁判文书的统计分析

陈思融*

内容提要 修改后的《中华人民共和国行政诉讼法》第 76 条规定了一种“新”的判决方式——补救判决。早在最高人民法院 2000 年发布的司法解释中就初步确立了该种判决方式,但并未引起足够的重视和关注,司法实践对于该判决方式的适用也存在较大差异,这在一定程度上影响了补救判决的法律效果。因此,以人民法院裁判文书为依据,对补救判决的适用情况进行归纳分析,不仅有助于修法后补救判决的正确适用,而且对于提升法院补救判决的质量,维护司法权威,具有重要的理论和实践意义。

关键词 行政诉讼 补救判决 行政裁判文书

一、引言

新《行政诉讼法》^①第 76 条规定:“人民法院判决确认违法或者无效的,可以同时判决责令被告采取补救措施……。”其中,“判决责令被告采取补救措施”即明确规定了一种“新”的行政诉讼判决形式——补救判决。事实上,在新《行政诉讼法》颁布前,最高人民法院相关司法解释就已经对“采取补救措施”作出过规定。^②由于相关司法解释并未以“判决”一词明确“采取补救措施”的性质,因而行政法学界对于该判决方式并未给

* 浙江财经大学法学院讲师,法学博士。

① 本文的新《行政诉讼法》是指于 2014 年 11 月 1 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过修改决定,并于 2015 年 5 月 1 日起施行的《中华人民共和国行政诉讼法》。

② 在我国现行的行政诉讼法以及司法解释法律文本中,涉及行政诉讼“补救判决”的法条共三个:(1)《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》(以下简称《解释》)第 58 条规定:“被诉具体行政行为违法,但撤销该具体行政行为将会给国家利益或者公共利益造成重大损失的,人民法院应当作出确认被诉具体行政行为违法的判决,并责令被诉行政机关采取相应的补救措施;造成损害的,依法判决承担赔偿责任。”(2)《解释》第 59 条第 2 项的规定:“根据行政诉讼法第五十四条第(二)项规定判决撤销违法的被诉具体行政行为,将会给国家利益、公共利益或者他人合法权益造成损失的,人民法院在判决撤销的同时,可以分别采取以下方式处理:……(二)责令被诉行政机关采取相应的补救措施;”(3)《最高人民法院关于审理政府信息公开案件若干问题的规定》(以下简称《信息公开司法解释》)第 11 条第 1 款的规定:“被告公开政府信息涉及原告商业秘密、个人隐私且不存在公共利益等法定事由的,人民法院应当判决确认公开政府信息的行为违法,并可以责令被告采取相应的补救措施”。

予足够的关注。与之相反,司法实践中却存在相当数量采用补救判决的案例,只是在判决依据、方式、内容等方面存在较大差异。^③ 因此,从行政审判实践出发,分析研究补救判决的地位、性质及适用方式等,对于指导和规范行政审判实践,尤其是统一新《行政诉讼法》补救判决条款适用,有着极为重要的意义。

本文的研究思路为:通过对涉及补救判决的行政裁判文书的分析与归纳,充分展示行政审判实践中“补救判决是怎样的”,并依据行政诉讼法理,揭示补救判决的“应然”要求,进而为新《行政诉讼法》第76条的准确适用奠定基础。

二、案例样本概况

由于各地裁判文书公开状况的差异,严格说来,本文收集的全国各地涉及补救判决的104份行政裁判文书不免带有一定的“偶然性”。^④ 然从案件发生的时间、地点及案件类型来看,仍不失一定的代表性:这些案件的审理时间介于1991年至2013年,几乎与我国现行行政诉讼法施行时间完全重合,地域方面涵盖我国东部、中部、西部等省份,判决主体包括基层、中级、高级法院等。104个案件的基本情况如表1所示:

表1 适用补救判决的案件类型

案件类型	数量	所占比例
土地使用权争议	25	24%
农业行政给付	18	17.3%
土地征收与房屋拆迁案件	14	13.5%
城市规划	11	10.6%
行政登记	8	7.7%
行政强制措施	6	5.8%
行政处罚	5	4.8%
养老、工伤、人事行政	4	3.8%
侵犯经营自主权	4	3.8%
燃气、供热、探矿权许可	3	2.9%
行政征收	3	2.9%
其他	3	2.9%

③ 参见陈思融:《行政诉讼撤销并责令补救判决论》,载《四川师范大学学报》2014年第2期。

④ 本文收集的行政审判案例和判决书的来源主要有:北大法宝数据库;北大法意数据库;沈德咏:《最高人民法院公报案例大全》,人民法院出版社2009年版;最高人民法院中国应用法学研究所:《人民法院案例选》(1992-1996年合订本)(行政卷),人民法院出版社1997年版;国家法官学院、中国人民大学法学院:《中国审判案例要览》,中国人民大学出版社1992-2012年版;最高人民法院行政审判庭:《中国行政审判案例》,中国法制出版社2010年版;北京市高级人民法院:《北京法院指导案例》,知识产权出版社2006年版;等等。

上表可见,大部分补救判决都出现在土地使用权争议、土地征收与房屋拆迁、农业行政给付以及城市规划案件中,所占比例超过百分之六十,这些案件讼争的内容与土地等不动产的利用有直接或间接关联。在我国,土地为国家所有或集体所有,一般而言,土地及地上的房屋及其附属物的价值较大,牵涉到土地、房屋所有权人及使用权人等多方利益,因此在行政争议裁决过程中若是仅作出撤销违法行为或者确认行政行为违法的判决,难以从根本上化解各方的争议,更不要说平衡相关各方的利益关系了。正因为如此,补救判决在此获得了广泛的适用空间。从当事人起诉的动因来看,这些案件可以概括为以下四类:(1)原告因土地使用权争议而提起的诉讼,如因政府将自己享有使用权的土地再次向第三人发放土地使用权证,或者收回或注销原告享有的土地使用权(证)而提起的诉讼;(2)原告因相邻权争议而提起的诉讼,如因行政机关向第三人颁发建设工程规划许可证而影响通风、采光等提起的诉讼;(3)原告因土地或房屋所有权争议而提起的诉讼,如因政府征收土地或者颁发房屋拆迁许可证而提起的诉讼;(4)原告因征地补偿费争议而提起的诉讼,如因村委会拒绝发放征地补偿费等费用而提起的诉讼。在行政登记、行政强制措施、行政处罚、侵犯经营自主权等案件中,适用补救判决时也都会有一个共同的特点,即如果仅作出撤销违法行为或者确认行政行为违法的判决,将无法弥补违法行为对原告或者第三人造成的不利。由此可见,人民法院适时地适用补救判决,将有助于从根本上化解行政争议,实现案结事了。

三、补救判决在司法实践中的运用

行政裁判文书,不仅是法院行政司法行为的表现形式,也是行政案件处理结果的表现,更是行政审判活动的记录本。^⑤ 研究分析包含补救判决的裁判文书,能够在全面了解行政诉讼审判活动的基础上,如实掌握补救判决在行政审判中的适用状况,进而为补救判决制度完善和正确适用奠定坚实基础。

(一) 补救判决的法律依据

1989年颁布的行政诉讼法文本中并无补救判决的规定。从规范依据来看,补救判决来源于最高人民法院的司法解释,共有三条,即《解释》第58条、59条第2项和《信息公开司法解释》第11条第1款。在司法实践中,涉及补救判决的法院裁判文书的法律适用情况如下:

^⑤ 参见黄启辉:《行政诉讼一审审判状况研究——基于对40家法院2767份裁判文书的统计分析》,载《清华法学》2013年第4期。

表2 补救判决的法律依据

法律依据	数量	所占比例
依据《解释》第58条	47	45.2%
依据《解释》第59条第2项	39	37.5%
依据《解释》第58条以及《解释》第59条第2项	3	2.9%
依据《信息公开司法解释》第11条第1款 ^⑥	0	0
无法律依据 ^⑦	15	14.4%

《解释》第58条一般被解读为中国情况判决制度的实定法渊源。^⑧ 情况判决的核心内容有二:一是被诉行政行为为违法应予撤销,二是撤销违法行为很可能造成国家利益或公共利益的重大损失。但情况判决并不意味着,为了维护公共利益而置个人利益于不顾,^⑨因此,必须对因避免“国家利益”或者“公共利益”损害而做出牺牲的个人利益进行必要的补救。由于情况判决适用条件明确稳定,所以《解释》第58条成了我国司法实践中补救判决最为广泛的规范依据。需要说明的是,在我们收集的全部案卷材料中,以《解释》第58条作为判决依据共有75件,只有47件包含“责令补救”的内容(其中有26件仅在判决主文中简单地以“责令某某采取相应补救措施”方式表达),^⑩其余28件仅作确认违法的判决而没有涉及责令补救的内容。^⑪

表2数据显示,依据《解释》第59条第2项作出补救判决的案件数与适用《解释》第58条的案件数并无太大差异,但在地域分布上却极不均衡。通过对案卷材料的阅读发现,适用《解释》第59条第2项作为补救判决依据的39份判决中,有19件都是山东省东营市中级人民法院作出的,其余20件则分布在河南、湖南、海南、江西、广东、安徽、重庆等7个省份,这与依据《解释》第58条作出补救判决的法院几乎涵盖了我国所有省份的情形形成鲜明的对比。之所以会出现这种情形,一个可能的原因是,《解释》第59条第2项表述太过简单,加之学界对补救判决缺乏必要的研究和关注,因而该规定所蕴含的潜在价值没有得到应有的重视和发掘。例如,在“何九泉与闫兴府土地行政处理决定

⑥ 在笔者收集的全部案例材料中,并未有依据《信息公开司法解释》第11条第1款作出补救判决的案件。

⑦ “无法律依据”是指在法院判决中,责令被告采取补救措施并未明示相关法律依据。从判决的时间来看,这类案件均在2000年《解释》出台以前,这在很大程度上也说明,行政审判的确需要补救判决。

⑧ 薛刚凌教授认为,这是典型的情况判决的规定。参见薛刚凌:《行政判决制度研究》,载《河南省政法管理干部学院学报》2003年第2期。江必新大法官指出,这是一种具有情况判决实质的判决,但他将其称为“变通性判决”。参见江必新:《中国行政诉讼制度之发展——行政诉讼司法解释解读》,金城出版社2001年版,第140页。甘文法官将该规定称之为“情势判决”。参见甘文:《行政诉讼法司法解释之评论——理由、观点与问题》,中国法制出版社2000年版,第165页。

⑨ 参见杨海坤、黄学贤:《行政诉讼:基本原理与制度完善》,中国人事出版社2005年版,第332页。

⑩ 如“杭州市规划局等与常某等规划行政许可纠纷上诉案”,具体案情参见浙江省杭州市中级人民法院(2011)浙杭行终字第247号行政判决书。

⑪ 如“某市政府等与某药业公司土地行政登记并颁证纠纷上诉案”,具体案情参见湖北省高级人民法院(2012)鄂行终字第00001号行政判决书。

纠纷上诉案”^⑫中,一审法院在判决理由中写道,“原告对其颁发证书的行为享有信赖利益,且现原告已完全具备规划宅基地条件,并已在争议宗地上建有房屋,应以完善其手续为妥”,并在判决主文中作出补救判决;再如在“黄雨和、黄水与麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府行政作为案”^⑬中,二审法院在判决理由中写道,“根据《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第五十九条第(二)项之规定,被上诉人黄桑乡人民政府应采取相应的补救措施。上诉人主张恢复原状,依法应予以支持。”不难看出,只有在法官们充分认识到《解释》第59条第2项规定所具有的弥补信赖利益损失、恢复原状等功能,才能在案件审理过程中自觉适用这一规定并作出补救判决。

除上述案例外,笔者注意到,法院作出的补救判决还存在同时援引《解释》第58条和第59条第2项的情形,这样的判决书共有3份,^⑭它们的共同特点是,法院一方面认为被诉行政行为违法,另一方面基于第三人利益而不是国家利益或公共利益的考虑而认为不宜判决撤销该违法行政行为。由于第三人利益并不在我国情况判决考虑范围之内,因而单纯援用情况判决条款作出补救判决难免构成适用法律错误。而《解释》第59条虽有斟酌第三人利益作出判决的规定,但其判决方式又必须是撤销判决。于是法官便同时援引这两个条款,试图通过规范的“嫁接”来化解这一困境。显然,这种作法并不能真正化解法律适用方面存在的问题,但却引发了两个值得深思的问题:基于私人利益的考虑,为什么不能作出情况判决?除《解释》第58条、59条第2项规定的事由外,补救判决是否还存在其他的适用空间?对于前者,行政法学界以肯定性认识居多;^⑮对于后者,除最高人民法院2010年发布的《信息公开司法解释》作出明确规定外,司法实践中也进行了一定的探索。例如,在“海口市美兰区灵山镇灵山村村委会大统上经济社与海口市人民政府颁发国有土地使用证纠纷上诉案”^⑯中,法院认为“0923号《国有土地使用证》(违法行政行为所颁之证)已注销,不具有可撤销的内容,故该颁证行为不宜撤销”,因此只能依据《解释》第57条第2款第2项的规定判决确认违法,但该判决内容并不能满足原告的诉求,于是法院又依据《解释》第58条的规定,判决“海口市人民政府对此采取相应的补救措施”。在“户县太平河管理站诉户县国土资源局房屋拆除纠纷案”^⑰中,法院也进行了类似的法律适用及判决。可见,在其他事由判决确认违法或无效的情形下,判决被告采取一定的“补救措施”对

⑫ 具体案情参见河南省新乡市中级人民法院(2010)新行终字第873号行政判决书。

⑬ 具体案情参见怀化市中级人民法院(2010)怀中行终字第2号行政判决书。

⑭ 三个案件分别为:“青岛万和热电有限公司与青岛市某区政府行政许可案”,山东省高级人民法院(2009)行终字第8号行政判决书;“齐永祥与息县人民政府违法颁发土地使用证案”,河南省信阳市中级人民法院(2011)信行终字第32号行政判决书;“张宏载与光山县城乡规划局等城市建设用地规划行政许可纠纷案”,河南省信阳市中级人民法院(2011)信中法行终字第31号行政判决书。

⑮ 参见黄学贤:《行政诉讼中的情况判决探讨》,载《行政法学研究》2005年第3期。

⑯ 具体案情参见海南省高级人民法院(2006)琼行终字第057号行政判决书。

⑰ 具体案情参见陕西省户县人民法院(2002)户行初字第16号行政判决书。

于化解行政争议,实现当事人的诉讼目的非常必要。

这种必要性,甚至我国行政诉讼法颁行初期就已经显现。例如,在“吴西碧诉广东省湛江市霞山区人民政府侵犯其经营自主权纠纷案(1991年判决案件)”^⑩中:

原告吴希碧于1989年5月与调丰、边坡两村签订《调丰村、沙坡村沙场承包协议书》,由原告开采属调丰、边坡两村共同使用的沙沟。1991年6月15日,湛江市霞山区沙石土管理所发给调丰、边坡两村沙场土石管第91001号《沙土石资源开采许可证》,开采期限:从1991年6月6日开始至1993年6月。1991年6月19日,吴希碧向霞山区工商行政管理局申领了开采沙场的06607号《营业执照》。此时,霞山区海头乡人民政府向霞山区人民政府呈上《关于承包坛上管理区沙区开发的请示》要求由其同意开发调丰、边坡沙场。霞山区人民政府于1991年8月7日作出同意该请示的批复,并指令国土、工商、公安部门禁止吴希碧开采。同年9月11日,霞山区沙石土管理所向调丰、边坡沙场和吴希碧发出通知,以吴希碧与调丰、沙坡签订的协议不具有法律效力为由,宣布该所发出的91001号《开采许可证》作废。并同时通知吴希碧停止开采。法院以该通知没有事实和法律依据为由,判决撤销了该通知,同时判决“被告湛江市霞山区沙石土管所1991年6月15日发给原告的湛霞沙石土管第91001号《沙石土资源开采许可证》继续有效,开采期限予以延长,延长时间:从1991年9月14日起至本判决发生法律效力止的总天数。”

该案中,法院在撤销违法行政行为的同时作出的“91001号《沙石土资源开采许可证》继续有效”的判决,其功能与《解释》第59条第2项的规定并无二致。也就是说,若判决撤销违法行为并不能完全解决行政争议,尤其是对原告的权益不能实现有效救济的情况下,法院若不能判决要求被告采取相关措施,就难以扭转违法行为给当事人造成的不利益后果。值得注意的是,该案判决甚至没有停留在“采取补救措施”这种抽象表述上,而且还对补救对象、补救方式等作出了具体要求,从而使得该判决具有很强的可操作性。

(二) 补救判决的基础

从法院审判权与当事人诉权间的关系来看,可以将诉讼模式区分为“当事人主义”与“职权主义”两种。“当事人主义”是指在诉讼中,当事人居于核心地位,诉讼请求的确定,诉讼资料和证据收集和证明等概由当事人负责。当事人甚至对法律的适用亦有选择的权利,法官在诉讼中处于中立的地位,他从不主动去干预某一方,而是充分尊重当事人的意志。“职权主义”则强调法官在诉讼中的主动性,更注意法官职能的发挥,法官对寻求案件事实真相负有责任,诉讼以法官的主动行为而展开。在这种诉讼模式中,当事人双方尽管也具有平等的诉讼权利和义务,但受到法官较多控制,法官不是消极的

^⑩ 具体案情参见最高人民法院中国应用法学研究所:《人民法院案例选》(1992-1996年合订本)(行政卷),人民法院出版社1997年版,第707-711页。

裁判者,而是诉讼的积极参与者。具体到我国行政审判实践,补救事项是法院依职权审查事项还是依当事人请求审查事项,认识并不完全一致。

表3 补救判决的基础

补救判决基础	数量	所占比例
依当事人诉请作出	40	38.5%
依职权作出	64	61.5%

如表3所示,在104个案件中,有64个案件的补救判决是法院依职权迳行作出的。例如,在47个依据《解释》第58条作出补救判决的案件中,仅有9个存在当事人的“补救”请求,其余38个均是法院依职权作出补救判决;在以《解释》第59条第2项为依据的42份(包含依据《解释》第58条以及59条第2项的3份)判决中,当事人提出补救诉请的案件有24份,另外18个案件是法院依职权作出的;在无法律依据的15个案件中,法院依职权和依当事人诉讼请求作出的补救判决的比例为8比7。

尽管法院依职权作出补救判决的案件在数量上居多,但在行政审判实践中,当事人甚至是法院对此是有不同意见的。如在“内乡县人事劳动和社会保障局与谢某某劳动人事行政管理纠纷再审案”^①中,内乡县人事局上诉称:“……谢某某起诉仅请求撤销让其退休的具体行政行为,但一审再审判决上诉人在一月之内通知教育局补发申请人的工资,属超范围审理,判决不当。”二审法院基本认同了上诉人的这一意见,其在判决理由中认为:“一审再审判决撤销被诉具体行政行为是适当的,但判令内乡县人事局通知谢某某主管部门补发申请人自2000年1月至2004年12月期间应享受的各种工资待遇缺乏相应法律依据,应予撤销。”本案中,上诉人及二审法院的逻辑在于,法院作出补救判决应当以当事人的诉讼请求为基础,在不存在当事人该项诉讼请求的情况下,法院作出补救判决就是超范围审理,这不符合司法权的中立性和被动性。笔者认为,该种观点虽然不无道理,但是却不符合行政审判权的特点。

依据诉讼法原理,诉讼程序的进行是以作出实体判决为目标的,为达到这一目标,诉讼过程中必须审查认定三类要件:起诉要件、诉讼要件和本案要件。^②就审查方式而言,一般认为起诉要件和诉讼要件属于职权审查事项,本案要件即案件实体争议部分应采取处分权主义和辩论主义的审理方式。^③但在行政诉讼有限职权主义诉讼模式下,^④

^① 具体案情参见河南省南阳市中级人民法院(2009)南行再字第27号行政判决书。

^② 参见肖建华:《民事诉讼当事人研究》,中国政法大学出版社2002年版,第84-90页。

^③ 参见[日]中村英郎:《新民事诉讼法》,陈刚等译,法律出版社2001年版,第153-157页;杨建华:《问题研析:民事诉讼法》,台湾三民书局1997年版,第95页。

^④ 行政诉讼的职权主义诉讼模式,在大陆法系国家和地区的行政诉讼制度中都有不同程度的表现,并在学理上得到广泛认可。参见[日]南博方:《行政诉讼中和解的法理》,杨建顺译,载《环球法律评论》2001年春、秋季刊;王名扬:《法国行政法》,中国政法大学出版社1989年版,第639页;刘宗德、彭凤至:《行政诉讼制度》,载翁岳生主编:《行政法》,中国法制出版社2002年版,第1401页;等等。

对于本案要件中的部分事项,在法律规定的情况下,也可采取职权主义审查方式。即对于这部分事项的审查,不必以当事人的主张或异议为前提,而由法院主动依职权发起调查并作出判断。对此,我国相关司法解释也有所体现。例如,根据《解释》第58条的规定,法院若作出确认违法的判决就必须同时责令被告采取补救措施,这是人民法院的一项义务(我们称之为“应为补救判决”);而《解释》第59条第2项、《信息公开司法解释》第11条第1款则授权法院“可以”责令被告采取补救措施(我们称之为“可为补救判决”),即是否作出这样的判决,法院享有裁量权。可见,在行政审判实践中,无论当事人是否诉请被告采取补救措施,法院均可以依职权进行审查并作出判决。

事实上,法院依当事人诉讼请求作出补救判决的案件仍然带有某种“职权主义”的色彩。在依当事人诉讼请求作出补救判决的案件中,原告的诉请皆为复数,即原告并没有直接提出“采取补救措施”的诉讼请求,而是在提出撤销行政行为或者确认行政行为违法的同时,请求法院责令行政机关作出诸如返还财产或恢复原状等,以扭转违法行政行为对其已经造成的不利益后果。例如,在“黄雨和、黄水与麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府行政作为案”^{②③}中,原告“要求确认被告的行政行为违法,并判令恢复原状”;在“董兰诉郑州市社会保险事业管理局企业养老保险待遇纠纷案”^{②④}中,原告“请求撤销被告按企业养老保险为其调整养老金的具体行政行为,并按国家对事业单位的相关规定给原告调整养老金”;在“钟细丁与韶关市浚江区人民政府土地行政信访、土地行政征收以及行政赔偿纠纷案”^{②⑤}中,原告“请求判决被告实施的韶浚府[2009]104号征地公告违法,恢复农田原状并归还”;在“海口市人民政府等与海南凯鹏房地产开发有限公司土地行政管理纠纷上诉案”^{②⑥}中,原告请求“撤销《收回国有土地使用权决定书》,返还国有土地使用权及等值置换已被海口市绕城高速公路占用地”;等等。很明显,在这些案件的判决中,法院“依职权”采用“采取补救措施”回应了当事人“返还财产”“恢复原判”等诉讼请求。

(三) 补救判决的形式

根据判决在诉讼中的地位和作用,行政判决可以划分为主判决和从判决。^{②⑦} 这种划分的意义在于理顺各种判决方式之间的联系,便于法院针对不同的诉讼请求选择不同的判决方式。所谓主判决,是指不依附其他判决方式而独立存在,且能对原告诉讼请求作出回应的判决种类;所谓从判决,是指依附于主判决而存在,主要针对行政机关履行法定职责或给付义务作出的判决。我国现有行政诉讼判决方式中,维持判决、撤销判决、变更判决、确认判决、驳回诉讼请求判决为主判决,而依附于撤销判决之后的重作判

^{②③} 具体案情参见怀化市中级人民法院行政判决书(2010)怀中行终字第2号行政判决书。

^{②④} 具体案情参见河南省郑州市中级人民法院(2012)郑行终字第93号行政判决书。

^{②⑤} 具体案情参见广东省高级人民法院行政裁定书(2013)粤高法行终字第164号行政判决书。

^{②⑥} 具体案情参见海南省高级人民法院(2008)琼行终字第3号行政判决书。

^{②⑦} 参见杨临宏、黄金泉:《中国行政诉讼的制度缺失及完善问题研究》,云南大学出版社2010年版,第204页。

决即为典型的从判决。^② 相较于主判决可以独立作出的特点,从判决只能依附于主判决而作出,即从判决需要依附于主判决之下,具有附随性。从判决存在的意义在于,解决法院在作出某些主判决后,不能满足原告的诉讼目的,或者不能完全解决行政纠纷,或者不能有效地监督和纠正被告的违法行为而附带于主判决作出辅助性判决。可见,主判决是从判决的前提和基础,从判决是主判决的补充和完善,两者是一个完整判决的有机组成部分。

表4 补救判决的形式

判决形式	数量	所占比例
主判决形式	15	13.2%
从判决形式	89	86.8%

从《解释》第58条、第59条第2项以及《信息公开司法解释》第11条第1款这三个条款来看,我国现有的补救判决均为“从判决”,分别依附于撤销判决和确认违法判决这两种主判决方式,司法实践中更多的也严格按照法律规定将补救判决以从判决的形式予以适用。然而如表4所示,行政审判实践中也有未拘泥于法律规范的表述,而是创造性地将补救判决以主判决形式加以适用的判决。在15个以主判决形式出现的补救判决案件中,有14个案件出自山东省东营市中级人民法院之“手”,其案件类型均为农业行政给付类型案件,即村委会拒绝向原告发放土地补偿款。由于在这类案件中,被告的“拒绝行为”没有任何载体,甚至只是构成事实上未向原告发放土地补偿款,因此当法院审理认为这种拒绝行为侵犯了原告的合法权益后,便直接依据《解释》第59条第2项作出要求被告向原告发放土地补偿款的判决。如“何晗等与垦利县垦利镇复兴村村民委员会农业行政给付上诉案”^③中,由于村委会拒绝发放款项只是一种事实,因此法院在判决时迳行依据《解释》第59条第2项作出要求村委会发放相应款项的补救判决。^④ 从本案讼争的内容看,“补救判决”的适用具有明显的合理性。因为在本案中,当法院欲支持原告的诉讼请求时将面临着如何选择恰当的给付判决方式的问题:在目前公认的具有给付性质的判决方式中,重作判决和行政赔偿判决明显不适合本案,而我国《行政诉讼法》第54条规定的履行判决,按照立法的严格规定,只能适用于被告不作为案件,对被告作为的案件则不能适用,因为法院在本案中将村委会拒绝发放款项行为认定为行政作为

② 对于重作判决的从判决形式或者说其附随性性格的认识,学界和实务比较一致。有关附随性特征的相关论述,参见章剑生:《判决重作具体行政行为》,载《法学研究》1996年第6期;石佑启:《判决被告重作具体行政行为探析》,载《上海市政法管理干部学院学报》2001年第5期;杨海坤:《行政诉讼法学》,中央广播电视大学出版社1994年版,第199页;张正钊:《行政法与行政诉讼法》,中国人民大学出版社1999年版,第385页。

③ 具体案情参见山东省东营市中级人民法院(2004)东行终字第61号行政判决书。

④ 类似案例还可参见:“段田田与段家村村委会农业行政给付上诉案”,山东省东营市中级人民法院(2004)东行终字第22号行政判决书;“孙卫诉广饶县广饶街道一村村民委员会农业行政给付纠纷案”,山东省东营市垦利县人民法院(2010)垦行初字第13号行政判决书;等等。

行为,^①因而履行判决无法适用。在此情况下,法院创造性地选择了同样具有给付性质的补救判决,充分反映了该院对补救判决方式的重视和灵活运用。其实,将上述案件中“补救判决”视为“主判决”,并不准确,因为法院在这里作出的责令采取补救措施的判决中,隐含着—个前提,即村委会拒绝发放款项行为已经被确认违法。

可见,以“主判决”方式呈现的补救判决只具—种表象,究其实质,补救判决只能处于从属地位。这种从属地位从当事人的诉请也得到了佐证。例如,在表3所示的40个以当事人诉请作出补救判决的案例中,不仅当事人的诉请是复数,而且只有在法院认同当事人撤销或确认行政行为为违法诉请的时候,才作出责令采取补救措施的判决。

(四) 补救判决的位置

就结构而言,判决书分判决说理和判决主文。在行政判决书中,责令补救的内容是出现在说理部分还是在主文部分,直接决定着既判力的有无。按照大陆法系通说,既判力客观范围原则上只限于判决主文中的判断,而判决理由中的判断(在判决理由中所认定的事实)一般是—没有既判力的。^② 行政诉讼判决的既判力,原则上也只针对当事人请求解决纷争的事项所作出的判断而发生,或者说只针对判决主文中的法院判断而发生。^③ 2004年最高人民法院执行工作办公室作出《关于以判决主文或判决理由作为执行依据请示的复函》^④也指出,“判决主文是人民法院就当事人的诉讼请求作出的结论,而判决书中的‘本院认为’部分,是人民法院就认定的案件事实和判决理由所作的叙述,其本身并不构成判项的内容。人民法院强制执行只能依据生效判决的主文,而‘本院认为’部分不能作为执行依据。”

表5 补救判决的位置

补救内容位置	数量	所占比例
判决理由和判决主文	71	68.3%
判决主文	32	30.8%
判决理由	1	1%

① 有学者将行政拒绝行为分为拒绝履行法定职责的行为和履行了法定职责后的拒绝行为,并认为这两种行为虽然在形式上都是行政主体作出的拒绝行为,相对人都没能获得所希望的结果,但两者有着本质的不同,前者本质上是一种不作为行为,并将其称为“不作为型拒绝行为”,即不履行法定职责的拒绝行为;后者本质上则是一种行政作为,并将其称为“作为型拒绝行为”,即行政主体履行了法定职责后的拒绝行为。参见王克稳:《论行政拒绝行为及其司法审查——以郑广顺申请规划认定案为例》,载《安徽大学法律评论》2009年第2辑。笔者赞同王克稳教授的观点并与法院观点—致,认为在上述两类农业行政给付案件中的拒绝行为属于履行了法定职责后的拒绝行为,即作为型行政拒绝行为。

② 林剑锋:《民事判决既判力客观范围研究》,厦门大学出版社2006年版,第58页。当然,在理论上,也存在主张赋予判决理由中的判断以拘束力的观点,参见田勇军:《论我国行政诉讼中法定判决理由既判力——以撤销诉讼为视角》,载《政治与法律》2011年第2期;朱川、周晶:《判决理由由既判力的再认识》,载《人民司法》2011年第8期;等等。

③ 参见杨建顺:《论行政诉讼判决的既判力》,载《中国人民大学学报》2005年第5期。

④ 最高人民法院执行工作办公室[2004]执他字第19号。

如表5所示,在104个判决中,有71个案件的判决书在判决理由和判决主文中均涉及责令补救的内容。在判决理由部分,法院着重对为什么需要判决责令补救,对谁进行补救,对何种不利益进行补救等进行了说明,然后在判决主文部分再次对补救措施的对象、对何种不利益进行补救,甚至对补救措施的履行期限作出规定,这样的判决书达60份之多。例如,在“董兰诉郑州市社会保险事业管理局企业养老保险待遇纠纷案”^⑤中,一审判决书先在判决理由部分中比较详细地说明为什么需判决责令补救,对谁进行补救,对何种不利益进行补救,然后在判决主文中明确写到:“被告郑州市社会保险事业管理局于判决生效后10日内对原告黄宇平的养老保险金采取相应的补救措施,并在补救措施落实之前继续按企业标准为原告黄宇平发放养老保险金。”显然,这种判决能较好的实现原告的诉讼目的,并使得判决的执行依据更加明确。

在样本案例中,有32份判决书仅在判决主文部分简单地以“责令某某采取相应补救措施”明确被告的补救义务。例如在“景德镇西郊垦殖场诉景德镇市房产管理局抵押登记案”^⑥中,一审法院仅判决撤销被告的违法行为,二审法院在维持一审撤销判决的同时,“责令上诉人景德镇市房地产管理局采取相应的补救措施”,但该二审判决理由中并未出现任何说明作出补救判决的理由方式等内容。这种判决方式在适用《解释》第58条作出补救判决时尤其突出。统计发现,在上列32个案件中,有26个案件的判决依据是《解释》第58条。在这些判决书中,法院通常将撤销被告行政行为可能会造成国家利益或公共利益的损失作为说理的重点,而对于判决确认被告行政行为违法时,是否以及如何采取补救措施不做任何说明。显然,这种不作“说理”的判决,其实效性是有疑问的。因为判决理由是法官根据各方当事人的主张或抗辩,在认定事实和适用相应法条的基础上进行推理,进而得出判决结论的具体根据,^⑦它具有防止审判任意性的保障机能,具有让当事人明白裁判的说明机能以及在上诉审中可依判决理由审查原判决正确与否的审查机能。^⑧如果法院只是判决采取补救措施而不作任何说理,难免给人造成法官有绝对的裁量权,没有需要说明的法律、事实和推理过程的假象。正如韦德指出的那样,“不说明裁决理由,当事人和法院就无法判断该裁决是否存在法律上的错误。因而,未能适当地说明裁决理由等于否定了公正,其本身就是一个法律错误。”^⑨

需要指出的是,在“陈某湖南某有限公司等规划管理行政许可纠纷案”^⑩中,一审判决撤销了被告违法行政行为,二审法院认为一审法院仅判决撤销违法行政行为不妥,其

⑤ 具体案情参见河南省郑州市中级人民法院(2012)郑行终字第93号行政判决书。

⑥ 具体案件参见刘家琛:《最高人民法院判例释解》,中国物价出版社2003年版,第208-212页。

⑦ 参见童兆洪:《商事审判的理论思辨》,人民法院出版社2008年版,第279页。

⑧ 参见肖晖:《论公开性是现代判决理由的本质特征》,载《北大法律评论》第4卷第2辑;[日]田口守一:《刑事诉讼法》,刘迪、张凌、穆津译,法律出版社2000年版,第287页。

⑨ [英]威廉·韦德:《行政法》,徐炳等译,中国大百科全书出版社1997年版,第673页。

⑩ 具体案情参见湖南省张家界市中级人民法院(2009)张中行终字第7号行政判决书。

在判决理由中写到:“陈某的房屋现已修至第六层,主体结构已接近竣工,撤销之后将造成该房屋的损失,根据《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第五十九条的规定,在判决撤销慈规管(2005)008号《建设工程规划许可证》的同时,应当责令慈利规划办采取相应的补救措施。原审判决未责令慈利规划办采取相应的补救措施不妥。”但二审法院在判决主文中并未判决补救,而是“驳回上诉,维持原判。”我们无从得知为何二审法院仅在判决理由中对补救内容加以说明,而在判决主文中不予提及,但此种将补救内容仅在判决理由中说明的做法,可能会产生如下问题:被告是否必须依据判决理由进行补救?如果被告未依据判决理由采取补救措施,权利人是否可申请强制执行?

(五) 补救判决的内容

法院在作出补救判决时是否应对“补救措施”的具体内容予以明示,司法实践中的作法并不统一。如表6所示,在104个案例中,法院在46个案例中明示补救措施的具体内容,而另外58个案例中,法院只是笼统地判决被告采取补救措施,但至于如何补救,判决未有涉及。

表6 补救判决的内容

补救措施内容是否明确	数量	所占比例
明确补救措施内容	46	44.2%
不明确补救措施内容	58	55.8%

行政诉讼的实质是司法权对行政权的审查,出于对行政权的尊重,司法权必须要保持必要的克制。正是基于这一点,更多法院在作出补救判决时并不明确补救措施的具体内容,以免有“僭越”之嫌。例如,在“海口市人民政府等与海南凯鹏房地产开发有限公司土地行政管理纠纷上诉案”^④中,针对一审法院判决“两被告于本判决生效之日起三个月内恢复未被海口市绕城高速公路占用的原告宗地土地(面积以实际测绘数据为准)的土地使用权,并为原告核发国有土地使用权证;两被告应为原告等置换已被海口市绕城高速公路占用的原告该宗土地(面积以实际测量的为准)”的内容,二审法院指出,“一审判决的第二项、第三项具体明确两上诉人应当作出补救措施的内容,亦属不当,应予纠正”,因此仅判决“上诉人海口市人民政府应在本判决生效之日起三个月内对被上诉人海南凯鹏房地产开发有限公司因收地造成的损失作出相应的补救措施”。再如在“董兰诉郑州市社会保险事业管理局企业养老保险待遇纠纷案”中,针对被告行政主体提出的“原审还要求上诉人在判决生效后10日内对原告的养老保险采取相应的补救措施,而一审并没有明确该补救措施的具体内容,上诉人无法执行”上诉理由,二审法院在肯定一审尊重行政权的作法同时,明确指出了行政机关裁量补救措施而应当考虑

④ 具体案情参见海南省高级人民法院(2008)琼行终字第3号行政判决书。

的因素:“一审判决所称的补救措施,上诉人可以在法律、法规和政策允许的范围内,在不侵犯公共利益和他人合法权益的情况下,合理裁量对被上诉人可以采取的补救措施,一审未予明确具体的措施内容,是基于对行政权的充分尊重。”

然在司法实践中,为了保证补救判决的实效性,同样也存在着明确补救措施具体内容的案件。例如在“何九泉与闫兴府土地行政处理决定纠纷上诉案”^②中,一审法院明确了补救措施的具体内容,其在判决书中写道:“原告对其颁发证书的行为享有信赖利益,且现原告已完全具备规划宅基条件,并已在争议宗地上建有房屋,应以完善其手续为妥”,二审法院也明确指出“原审判决责令应举镇人民政府采取补救措施,为闫兴府申请用地完善手续是正确的,应当予以支持”。再如在“内乡县人事劳动和社会保障局与谢某某劳动人事行政管理纠纷再审案”^③中,一审法院在判决主文中明确写道:“内乡县人事劳动和社会保障局在本判决生效后一个月内作出相应的补救措施(通知谢某某主管部门补发自2000年1月—2004年12月期间应享受的各种工资等待遇)”。

毫无疑问,行政诉讼中司法权对行政权的审查必须要遵循一定的限度,这是一个共识,但对于该原则的理解和把握,不同的诉讼主体是有差异的。正如二审法院在“董兰诉郑州市社会保险事业管理局企业养老保险待遇纠纷案”指出的那样,法院完全可以对“采取补救措施”作出一定的“指引”,这既是法院释明义务的内在要求,也可以提高补救判决的可执行性。

结 论

新《行政诉讼法》第76条规定:“人民法院判决确认违法或者无效的,可以同时判决责令被告采取补救措施……。”相较于有关司法解释,该条规定明确了“采取补救措施”是一种“判决”方式,而且必须与“确认违法或无效”判决“同时”作出,即只能居于“从判决”的地位。根据补救判决在司法实践中的运用情况,人民法院在适用新《行政诉讼法》该条规定时应当注意以下几点:

第一,补救判决是行政诉讼判决方式的一种。作为一种判决方式,补救判决必须在判决主文中得到体现,并且在判决书说理部分进行充分的说理。从司法实践来看,补救判决往往与土地、房屋等不动产物权争议有关,其功能在于“一揽子”解决当事人间的行政争议。

第二,补救判决是“从判决”。作为“从判决”,人民法院只有在作出确认违法或无效判决的情形下才可以判决被告“采取补救措施”,这实际上否定了《解释》第59条第2项规定的在作出撤销判决的同时亦可以适用的规定。这种立法中否定补救判决作为撤销判决

② 具体案情参见河南省新乡市中级人民法院(2010)新行终字第873号。

③ 具体案情参见河南省南阳市中级人民法院(2009)南行再字第27号。



从判决存在的做法是否合理,应该是一个值得进行深入讨论的问题。但如果严格按照新《行政诉讼法》的规定,由于修改后的《行政诉讼法》第74、75条所列举的撤销判决或确认无效判决的适用情形明显超出了《解释》第58条并与《解释》第59条第2项部分重叠,因而司法实践中可以适用补救判决的情形将更为广泛,但《解释》第59条第2项规定的以下两种情形将不再适用补救判决:一是撤销违法行政行为若对国家利益或社会公共利益损害达不到“重大”的程度,不能适用确认违法判决,自然也不存在补救判决的可能;二是撤销违法行政行为如果只对“他人合法权益造成损失”,不管该损失是否达至“重大”程度,均应判决撤销(部分撤销)而不是确认违法,因而也不能适用补救判决。

第三,补救判决的适用属于司法裁量权的范畴。从《解释》第58条、59条第2项的规定来看,前者为“并责令”采取补救措施,即具有“羁束性”,而后者是“可以责令”采取补救措施,即具有裁量性。在本文收集的样本案例中,共有75件适用了《解释》第58条作为裁判依据,但其中多达28件只确认违法而无责令补救内容。这种状况说明,情况判决中“责令采取补救措施”的规定事实上已处于“裁量”地位。正因为如此,新《行政诉讼法》第76条规定法院“可以”而不是“应当”同时作出补救判决。从补救判决的司法实践看,这种司法裁量权还包括,不管当事人是否诉请“采取补救措施”,法院均可以依职权进行审查并作出判决。

第四,出于对行政权必要的尊重,法院在作出补救判决时不能取代行政机关作出判断,但也不能笼统地以“责令采取相应补救措施”为之。在判决主文,尤其是说理部分应当对为何责令补救、对谁补救、对何种不利益进行补救等予以释明,以保证补救判决的实效性。

Abstract: There is a new form of judgment, remedial judgment, which is provided by the latest Administrative Procedure Law of the PRC. This kind of judicial method has been established in the judicial interpretation issued by the Supreme People's Court in 2000, but this kind of judicial method has not caused enough attention. In addition, there are great differences in using this kind of judicial method in judicial practice, and this affects the legal effect of remedial judgment in a certain extent. Therefore, it will not only help the correct application of remedial judgment after the law revised, but also enhance the quality of the judgment of the court remedies and safeguard judicial authority by summarizing and analyzing the application of the remedial judgment according to the administrative judgment documents.

(责任编辑:吴 雷)

